

Sistemi di composizione dei conflitti in California

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Per affrontare il sistema di ADR in California bisogna sapere in primo luogo che la risoluzione pacifica delle controversie in modo equo, tempestivo, opportuno e conveniente è considerata funzione essenziale del potere giudiziario californiano, ai sensi dell'art. VI della Costituzione¹.

Questo è da considerarsi il primo obbiettivo: l'intento deflativo è conseguente.

Ed incoraggiare le persone a partecipare ad una mediazione è considerato un pubblico interesse.

La preferenza è però assicurata agli strumenti ADR preventivi ed il legislatore nel Codice di procedura civile sollecita tutti i tribunali a partecipare a progetti pilota di mediazione preventiva come quello che è operante ad esempio nella Contea di Los Angeles e che poi esamineremo.

La regolamentazione dell'ADR è da rinvenirsi nella disciplina del Codice civile² e di Procedura civile³, in quelle del Codice relativo agli elementi di prova⁴, ma anche in regole comuni ad ogni Corte (*California rule of Court*) e infine a regole specifiche di ogni Corte (Los Angeles, Santa Barbara, Northern District)⁵.

Si deve anche tener presente che vi è un'organizzazione statale che in California detta norme di comportamento⁶ per tutti i compositori dello Stato⁷, ma che vi sono poi anche regole di comportamento specifiche per ogni Corte.

Detto ciò chi abbia necessità oggi di risolvere un conflitto in California e voglia utilizzare i metodi ADR può consultare tranquillamente il sito di ogni Corte che è obbligata⁸ a fornire

¹ Crf. sezione 1775 Codice di procedura civile della California; cfr. <http://www.mediationtools.com/rules/cc1775.html>

² Con riferimento agli ADR in materia di vizi di costruzione: sezione 1375; cfr. <http://www.mediationtools.com/rules/cc1375.html>

³ Cfr. <http://www.leginfo.ca.gov/>. Cfr. sezioni 1441 e 1775.

⁴ Sezione 730, 5 e Sezioni 1115-1128 California evidence Code

⁵ <http://www.mediationtools.com/rules/index.html>

⁶ Cfr. <http://www.cdrc.net/pg2.cfm>

⁷ La *Counsil Dispute Resolution* (CDRC) è una organizzazione statale di mediatori, arbitri, e di altri risolutori controversia neutrale di cui fanno parte rappresentanti di tutte le principali organizzazioni di risoluzione delle controversie in California, singoli professionisti di tutti i settori di enti pratica, pubblici e privati, giudici, formatori e accademici.

un pacchetto di informazione sugli strumenti di ADR e sui relativi eventuali programmi (DRPA⁹).

Alla base dell'obbligo di informazione c'è sicuramente anche una ragione di carattere economico perché il Codice di rito stima che per ogni giorno di giudizio la spesa ammonti a 3.943\$ e che tale costo può essere sensibilmente ridotto attraverso mezzi ADR preventivi¹⁰; si considera inoltre che un programma giudiziario di ADR possa avere successo nel momento in cui vi è un risparmio annuale di almeno 250.000 \$¹¹ e tutti gli operatori devono contribuire al raggiungimento di questo obiettivo che permette alle Corti di avere programmi di ADR finanziati (v. ad esempio il programma CADRe nella Contea di Santa Barbara).

In ogni caso da questo pacchetto di informazioni che si possono agevolmente visionare si possono ricavare diverse opportunità di ADR: *mediation; neutral evaluation, arbitration e settlement conferences*.

Per "mediazione" (*mediation*), si intende in generale una procedura in cui una persona imparziale chiamata "mediatore" (*mediator*) aiuta il tentativo delle parti di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile della controversia¹².

Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti affinché possano comunicare e cercare di risolvere la loro controversia. La mediazione lascia pertanto il controllo del suo esito alle parti.

La mediazione può essere particolarmente utile quando le parti hanno tra di loro una relazione che vogliono preservare.

Così, quando i membri della famiglia, i vicini o i partner commerciali sono coinvolti in una controversia, la mediazione può essere il processo di ADR più indicato da utilizzare.

⁸ Rule 1321, *Reorganized California Rules of Court* (in vigore dal 1 gennaio 2007). Cfr. <http://www.mediationtools.com/rules/crc3221.html>

⁹ *Dispute Resolution Programs Act*.

¹⁰ Sezione 1775 punto F del Codice di Procedura civile della California: "*It is estimated that the average cost to the court for processing a civil case of the kind described in Section 1775.3 through judgment is three thousand nine hundred forty-three dollars (\$3,943) for each judge day, and that a substantial portion of this cost can be saved if these cases are resolved before trial*". (Si stima che il costo medio al tribunale per l'elaborazione di una causa civile del tipo descritto nella Sezione 1775,3 attraverso il giudizio è 3.943 dollari (3.943 dollari) per ogni giorno di giudizio, e che una parte sostanziale di questo costo può essere eliminato se questi casi sono risolti prima del processo).

¹¹ Sezione 1775 punto F del Codice di Procedura civile della California, comma secondo.

¹² Cfr. <http://www.courts.ca.gov/3074.htm>

La mediazione per le Corti californiane è efficace anche nei casi in cui le emozioni in conflitto hanno già trovato una via di composizione.

Un mediatore può efficacemente ascoltare le parti e aiutarle a comunicare tra loro in modo costruttivo e non distruttivo.

La mediazione è opportuna quando le parti hanno voglia di lavorare insieme e trovare una soluzione che non implichi necessariamente il denaro, come ad esempio quando si chiede a qualcuno di cambiare il proprio modo di comportarsi.

La mediazione non è invece opportuna, secondo le Corti californiane, se una delle parti non è disposta a collaborare o a trovare un accordo.

La mediazione può anche non essere un metodo efficace se una delle parti riveste sull'altra una posizione di dominanza: non può essere dunque una buona scelta se le parti hanno tra loro intessuto una storia di abuso o di vittimizzazione¹³: ecco di questa impostazione lo ritroviamo anche nella legislazione tedesca.

La mediazione è innanzi tutto disciplinata dal Codice di procedura civile (Sezione 1775).

Bisogna tener presente che le norme della Sezione 1775 valgono per la Contea di Los Angeles; le altre Contee possono applicarla o meno e la scelta di ogni giudice è revocabile.

Davanti alla Corte di Los Angeles ed in altri tribunali che decidono di adottare la sezione 1775, per tutte quelle azioni civili per cui sarebbe praticabile un arbitrato¹⁴, se viene presentata una richiesta di pronuncia secondo equità, il Presidente od il giudice designato può decidere che in alternativa venga condotta una mediazione.

Ciò accade soprattutto quando le parti sono Enti od agenzie pubbliche¹⁵.

La determinazione di inviare un caso di mediazione deve essere effettuata dal giudice dopo l'esame dei pareri espressi dalle parti sulla riconducibilità del caso alla mediazione

¹⁶.

Se per un'azione è stato ordinato un arbitrato non potrà condursi una mediazione e viceversa¹⁷.

¹³ La Corte Suprema della California precisa i vantaggi della mediazione in <http://www.courts.ca.gov/3074.htm#tab4538>

¹⁴ Ai sensi della Sezione 1141,11 che prevede si utilizzi l'arbitrato davanti a Tribunali di una particolare composizione e per un valore inferiore ai 50.000 €.

¹⁵ v. Sezione 1775,3 A-B.

¹⁶ Rule 3,871 REORGANIZED CALIFORNIA RULES OF COURT.

Il giudice non può ordinare che un caso vada in mediazione se il valore della controversia è superiore ai 50.000 \$¹⁸.

Se un'azione viene sottoposta a mediazione deve essere nominato un mediatore entro 30 giorni dalla scelta della procedura. La scelta è fatta in base alla determinazione delle parti. Se entro 15 giorni dalla pronuncia le parti non si mettono d'accordo il mediatore viene scelto dal Presidente in base alle norme che regolano il Consiglio giudiziario¹⁹.

I mediatori e gli arbitri sono compensati nello stesso modo²⁰: 150 \$ per caso salvo che il Tribunale non scelga di corrispondere un valore superiore²¹.

Nel caso in cui le parti della mediazione non siano in grado di raggiungere un accordo reciprocamente accettabile ovvero se una delle parti della mediazione voglia porre fine alla mediazione, il mediatore deve presentare una dichiarazione di mancato accordo.

La dichiarazione deve essere effettuata sul modello (*form* ADR-100) predisposto da parte del Consiglio Giudiziario.

Il *form* ADR-100²² va presentato sia in caso di accordo che nella ipotesi di mancato accordo e prevede che il mediatore indichi le sue generalità, il suo indirizzo e i dati dell'invio del *form* stesso alle parti.

Nel *form* ADR-100 il mediatore deve anche specificare se la mediazione si è tenuta o meno: in particolare se la parte a cui è stato ordinato di partecipare alla mediazione non si sia presentata o se sussista un'altra ragione per la mancata celebrazione (che va indicata non venendo però meno al precetto della confidenzialità).

Se la mediazione si è tenuta va specificata la data e le ore di durata.

Se la mediazione non è terminata va indicato, qualora sia spirato, il termine assegnato dalla Corte.

In ultimo il mediatore deve dare atto che in una certa data c'è stato un completo accordo comune a tutte le parti o un accordo parziale, un completo accordo relativamente ad

¹⁷ Sezione 1775,4.

¹⁸ Sezione 1775,5.

¹⁹ Sezione 1775,6.

²⁰ Sezione 1775,8.

²¹ Sezione 1441, 18.

²² <http://www.courtinfo.ca.gov/forms/documents/adr100.pdf>

alcune parti o un parziale accordo, un pieno accordo con riferimento alle questioni per cui il giudice ha ordinato la mediazione, o infine appunto un mancato accordo.

Nel caso in cui il mediatore provveda alla redazione di un verbale di non accordo l'udienza processuale viene calendarizzata con la priorità che si avrebbe avuto se non ci fosse stata la mediazione stessa e possibilmente nel medesimo stato di fatto e di diritto²³.

Le dichiarazioni rese dalle parti in mediazione non possono essere oggetto di testimonianza da parte del mediatore, arbitro, giudice che presieda la procedura di ADR²⁴, sono irricevibili nel processo in quanto oggetto di una negoziazione²⁵.

Si tenga però presente che le prove altrimenti ammissibili o oggetto di *discovery* al di fuori di una mediazione o di una consultazione di mediazione non devono considerarsi o diventare inammissibili o tutelate esclusivamente in ragione della loro introduzione o dell'uso in una mediazione o in una consultazione mediazione²⁶.

Il mediatore o chiunque altro non possono presentare ad un Tribunale o ad un altro organo aggiudicativo, né il Tribunale od altro organo aggiudicativo possono ricevere, valutazioni o raccomandazioni o qualsivoglia relazione inerenti la mediazione che il mediatore abbia condotto e che siano diverse dal rapporto ordinato dal tribunale (*form* ADR-100), a meno che le parti non dispongano per iscritto in senso contrario²⁷.

Una comunicazione o una scrittura che sia preparata durante il corso di una mediazione non è irricevibile a patto che si verifichino una di queste condizioni: a) tutte le persone che dirigono o che altrimenti partecipano alla mediazione ne convengono per iscritto²⁸ la

²³ Sezione 1775,9.

²⁴ A meno che non diano luogo ad un oltraggio, ad un reato, ad un indagine dell'avvocatura dello Stato o della Commissione che valuta le prestazioni giudiziarie o diano luogo ad un procedimento di interdizione ecc. (Sezione 703, 5 California evidence Code).

²⁵ Sezione 1152 California evidence Code (v. però le eccezioni al punto c). La prova non è però pregiudicata in due casi: a) se si è affermata la parziale soddisfazione di un credito o si offre la parziale soddisfazione di un credito come prova del credito stesso in assenza di contestazione, b) se vi è stato il pagamento da parte di un debitore o la promessa di pagare tutti o una parte del suo debito preesistente, quando si tende a dimostrare la creazione di un nuovo obbligo da parte sua o di un rinnovo del suo dovere preesistente.

²⁶ Sezione 119 California evidence Code.

²⁷ Sezione 1121 California evidence Code

²⁸ Od oralmente con le garanzie della Sezione 1118. La sezione 1118 del Codice sulle prove della California prevede la possibilità di registrare l'accordo oralmente alla presenza di un reporter del tribunale e di firmarne il testo successivamente.

divulgazione; b) se la scrittura è stata preparata da alcuni partecipanti o per loro conto, questi partecipanti ne convengono per iscritto²⁹ la divulgazione³⁰.

Un accordo transattivo scritto e preparato nel corso di, o in virtù di una mediazione, non è irricevibile, o protetto dalla divulgazione ai sensi di legge se il contratto è firmato dalle parti e sussiste una qualsiasi delle seguenti condizioni: a) l'accordo prevede che esso sia ammissibile in un giudizio o oggetto di comunicazione, o parole in tal senso; b) l'accordo prevede che sia esecutivo e che sia vincolante o parole in tal senso; c) tutte le parti dell'accordo convengono espressamente per iscritto od oralmente in conformità della sezione 1118, alla sua divulgazione; d) l'accordo è utilizzato per dimostrare la frode, la coercizione, o la illegalità che è rilevante per una questione contestata.

Un accordo verbale può essere utilizzato se registrato in conformità della Sezione 1118 e sottoscritto nelle 72 ore dalla registrazione, se le parti convengono che esso sia esecutivo o vincolante oppure si utilizzi per dimostrare la frode, la coercizione, o la illegalità che è rilevante per una questione contestata.

Chi partecipa ad una mediazione non perde il diritto alla *discovery*³¹.

Ogni riferimento alla mediazione od al verbale di mancato accordo è da considerarsi una irregolarità processuale³².

La Contea di Los Angeles oltre a riconoscere la mediazione come appena descritta³³, aderisce all'accennato programma di mediazione obbligatoria preventiva³⁴: il giudice notifica alle parti che la loro causa è stata selezionata per una mediazione e le parti sono obbligate a parteciparvi.

Le parti sino a 5 giorni prima dall'udienza devono presentare una dichiarazione di EMSC (*Early Mediation Status Conference*) su un particolare modello approvato dalla corte (*EMSC statement*): in esso l'attore ed il convenuto descrivono la natura della causa, il tipo risarcimento richiesto ed il suo ammontare, se la questione può essere o meno oggetto del

²⁹ Od oralmente con le garanzie della Sezione 1118.

³⁰ Sezione 1122.

³¹ Sezione 1775,11

³² Sezione 1775,12. Potrebbe fondare la celebrazione di un nuovo processo (Sezione 657).

³³ Los Angeles Superior Court, Local Rule 12.15-12.16-12.17.

³⁴ EARLY MANDATORY MEDIATION PILOT PROGRAM. Los Angeles Superior Court, Local Rule 12.35 new and effective March 1, 2001.

programma di mediazione preventiva, se e chi eventualmente si opponga a tale programma ed il tempo che si ritiene congruo per portare avanti una mediazione³⁵.

Il Tribunale mantiene una lista di mediatori (*panel*) tra cui si può scegliere.

I mediatori della lista devono possedere 1) almeno trenta ore di formazione da mediatori, 2) aver completato almeno 8 mediazioni (ciascuna della durata di almeno due ore negli ultimi 3 anni), e 3) aver partecipato a 4 ore di formazione continua in un corso ADR approvato da un Istituto di formazione continua.

Inoltre i mediatori del tribunale si devono impegnare a rispettare la politica di rimborso e la procedura del tribunale, devono concordare di conformarsi alle norme del tribunale di condotta professionale dei mediatori; devono rispettare le regole della corte e le procedure per l'attuazione del programma pilota di mediazione obbligatoria, come stabilito dal Comitato di ADR e dall'Amministrazione dell'ADR³⁶.

Se le parti scelgono un mediatore al di fuori del *panel* esso deve essere autorizzato dal giudice che vi provvede caso per caso e l'assunzione della responsabilità per il pagamento ricade sulle parti stesse.

In difetto di pagamento il mediatore può chiedere il pagamento dei suoi onorari alla Corte³⁷, ma la somma non può essere superiore a quello che avrebbe chiesto un mediatore appartenente alla lista.

Entro 10 giorni dalla conclusione della procedura va inviato alla Corte un altro modello che si denomina *Adr Information form*: in esso si precisa sostanzialmente l'ammontare della controversia, che tipo di ADR si è utilizzato, se il caso è stato risolto o meno per merito della procedura ADR ed in ultimo se si sono risparmiati denaro e tempo (indicando la quantità presumibile di risparmio) rispetto al giudizio che era ordinariamente previsto per quella controversia³⁸.

In ordine alla mediazione la Corte Superiore di Los Angeles detta alcune regole locali che quindi non fanno parte né del Codice di procedura civile, né del Codice delle prove, ma che vanno conosciute.

³⁵ Los Angeles Superior Court, Local Rule 12.35.

³⁶ Los Angeles Superior Court, Local Rule 12.36.

³⁷ Accompagnandola al modello ADR-100 già visto.

³⁸ <http://www.courts.ca.gov/xbcr/cc/adr101.pdf>

Tra la data della citazione e l'udienza le parti possono scegliere di andare in mediazione in qualsiasi momento: all'uopo possono scegliere un mediatore del *panel* della Corte (i loro legali possono prendere con lui diretti contatti personali o telefonici) oppure fuori dalla lista³⁹.

Chi non si presenta (parte, rappresentante, avvocato) senza giustificato motivo ad una sessione di mediazione può incorrere in una sanzione pecuniaria da pagarsi al mediatore e agli altri partecipanti presenti⁴⁰.

Se si richiede la mediazione ci si deve preparare alla *discovery* con moderazione⁴¹; anche il progetto, purtroppo decaduto, della legge spagnola sulla mediazione ed il susseguente decreto reale ha previsto che le parti si debbano comportare seconda buona fede e quindi non debbano intentare giudizio se la mediazione è in corso⁴².

La Contea di Santa Barbara segue invece un programma di mediazione che è denominato CADRe (*Court Administred Despute Resolution*) e che ha come obbiettivo quello di risolvere le liti entro il termine massimo di sette mesi⁴³.

Tutto il contenzioso civile⁴⁴ deve passare attraverso questo programma di riduzione del ritardo delle cause civili ad eccezione delle questioni riguardanti i minori, le successioni, i rapporti domestici⁴⁵.

Al momento del deposito dell'atto introduttivo di una causa civile, la Corte assegna casualmente un giudice a conoscere della causa a tutti gli effetti.

Viene fissata anche un'udienza (*Case Management Conference*) da tenersi entro 120 giorni dalla data di deposito dell'atto introduttivo; il tutto viene comunicato all'attore.

³⁹ Los Angeles Superior Court, Local Rule 12.16.

⁴⁰ Los Angeles Superior Court, Local Rule 12.15.

⁴¹ Los Angeles Superior Court, Local Rule 12.17

⁴² L'art. 10 c. 2 del *Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles* recita testualmente: "Las partes en conflicto actuarán conforme a los principios de buena fe y respeto mutuo. Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no podrán interponer entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto".

⁴³ <http://www.sbcadre.org/index.htm>

⁴⁴ Rule 1309 ADMINISTRATION OF CIVIL LITIGATION.

⁴⁵ California Government Code Section 68608. Ciascun Corte Superiore stabilisce poi un programma di riduzione del ritardo delle cause civili in accordo con il COA locale (California Government Code Section 68620).

Quest'ultimo deve di norma notificare l'avviso della Corte alle altre parti entro 60 giorni e deve depositare la prova dell'avvenuta notifica entro 5 giorni dal perfezionamento; se la notifica fallisce o non si provvede si è passibili di sanzioni⁴⁶.

Sino a 15 giorni prima dell'udienza le parti devono depositare il modello CM-110 (*Case management statement*) nel quale i legali fanno un riassunto della questione, danno atto di aver discusso con i clienti circa un metodo ADR, indicano quale sia il metodo ADR preferibile.

Davanti alla Corte è, per inciso, possibile sperimentare l'arbitrato, la valutazione neutrale, le conferenze di accordo preventive ed in aggiunta sottoporre la questione agli *special masters or referees*.

Gli arbitri sono così definiti nelle Corti federali: di solito sono avvocati esperti o giudici in pensione.

Aiutano le parti a scambiarsi documentazione e possono risolvere il caso e fanno spesso *settlement conferences* con le parti per risolvere il caso insieme; di solito, l'arbitro suggerisce una soluzione alla Corte.

Il giudice può accogliere la raccomandazione e farla propria.

Le parti peraltro possono fornire l'arbitro di quanta autorità desiderano. Questo può rendere il processo più veloce.

Se vogliono, le parti possono anche concordare che la decisione dell'arbitro sia vincolante, ricorrere ad a un *judge pro tems* (sarebbero i giudici onorari che di solito sono avvocati).

Alla *Case management conference* (CMC) il giudice verifica *in primis* se l'importo in causa supera o meno i 50.000 \$⁴⁷: se non li supera il giudice dispone una particolare mediazione (*Limited mediation*) in luogo dell'arbitrato giudiziale.

Gli avvocati hanno disposizione dieci giorni di tempo per contattare il CADRe e vedersi attribuito un mediatore.

⁴⁶ Rule 1309 B ADMINISTRATION OF CIVIL LITIGATION. L'attore può chiedere anche un supplemento di tempo, ma se la notifica non va a buon fine il giudice può emettere all'udienza un *order to show case*, cioè può fissare un'udienza per avere maggiori ragguagli o prendere altri comportamenti limitativi delle facoltà dell'attore od irrogare anche sanzioni pecuniarie.

⁴⁷ La determinazione è vincolante ai fini dell'ADR, ma non della prova.

La mediazione si tiene nella data fissata dal giudice nella CMC, ma certamente prima dell'udienza destinata al tentativo obbligatorio di mediazione (*Mandatory settlement conference* o MSC).

Il contenuto della mediazione non potrà però mai superare il valore di 50.000 \$.

Il mediatore presenterà poi un *form* ADR-100 al Giudice.

Se il valore della causa non supera i 50.000 € il giudice fissa la data del processo ed invita i legali a proseguire entro 10 giorni la CMC (*Case management conference*) in una udienza davanti al direttore del CADRe che assegnerà alle parti un mediatore (*facilitator*)⁴⁸ perché sia condotta una sessione informativa⁴⁹ di tre ore che sono retribuite dalla Corte⁵⁰.

Le parti hanno 60 giorni per parteciparvi.

In tale sessione il *facilitator* provvede come da *report* del giudice e può anche preparare il caso e programmare la *discovery*; se il tempo lo permette conduce anche una *Conference settlement*⁵¹.

Se le parti vogliono continuare la mediazione oltre le tre ore possono farlo con lo stesso facilitatore o con un terzo, ma la responsabilità del pagamento della tariffa oraria del professionista ricade su di loro: la maggiorparte delle mediazioni dal 2005 al 2011 si sono chiuse in questo *extra time*⁵².

Se il tempo necessario per la stipula influisce sulla data dell'udienza processuale, le parti possono chiedere di fissare una nuova data.

Il facilitatore presenterà poi una relazione al giudice tramite la segreteria del CADRe, ma non potrà indicare dati sensibili come l'identità della parte che non si è impegnata a fondo nella sessione di ADR; in pratica scriverà se la sessione si è tenuta e chi era presente.

In alternativa alla CMADRESS le parti possono decidere di fare una mediazione privata con un proprio mediatore.

⁴⁸ Che fa parte del *panel* della Corte. Le parti non possono scegliere il facilitatore.

⁴⁹ Si tratta del programma CMADRESS (*Case Management ADR Early Settlement Session*) che fa a sua volta parte del programma CADRe).

⁵⁰ 100 \$ all'ora.

⁵¹ Aiuta cioè le parti a valutare i punti di forza e di debolezza del caso e a negoziare un accordo.

⁵² Cfr. <http://www.sbcadre.org/cadre/docs/statscmadress.pdf>

Essi però devono presentare al giudice prima della CMC il modello *ADR stipulation form* con cui spiegano che metodo hanno scelto e si impegnano a parteciparvi e a concludere la procedura entro l'udienza di MSC⁵³.

Dettagliate sono le norme delle Corti della California che regolano il comportamento dei mediatori durante la procedura e la procedura stessa di mediazione.

Si tratta delle disposizioni civilistiche che vengono osservate dal 2007 in tutti procedimenti davanti alle corti superiori, a meno che la legge od il regolamento delle corti superiori non dispongano diversamente⁵⁴.

Viene in campo in primo luogo nella regolamentazione il rispetto della volontarietà e della auto-determinazione delle parti.

La partecipazione volontaria e autodeterminazione sono principi fondamentali della mediazione che si applicano sia alle mediazioni in cui le parti volontariamente scelgono di mediare ed a quelle in cui le parti sono tenute ad andare alla mediazione in virtù di un programma obbligatorio di mediazione del tribunale o a seguito di un ordine del tribunale.

Anche se il giudice può ordinare ai partecipanti di partecipare alla mediazione, il mediatore non può fissare obblighi alla durata della partecipazione al processo di mediazione o costringere una delle parti ad accordarsi⁵⁵.

In particolare la norma 3,853 stabilisce che il mediatore deve condurre la mediazione in modo da sostenere i principi di partecipazione volontaria e di autodeterminazione delle parti.

A questo scopo un mediatore deve: (1) in primo luogo informare le parti, preventivamente o all'inizio della sessione di mediazione, che qualsiasi soluzione della controversia in mediazione richiede un accordo volontario delle parti; (2) rispettare il diritto di ogni

⁵³ Se le parti sono in buona fede e non riescono a concludere la mediazione prima della MSC il giudice può assegnare a quest'ultima un'altra data.

⁵⁴ V. Rule 3.10 Reorganized California Rules Of Court (al 1 gennaio 2011).

⁵⁵ *Advisory Committee Comment*. La Corte Suprema ha previsto dal 2009 una commissione giudiziaria (*Advisory Committee Comment*) per fornire pareri e consigli di etica giudiziaria per gli uffici. Nel fornire i pareri e consigli, il comitato agisce indipendentemente da tutte le altre entità. La commissione si basa sul codice etico della magistratura della California nonché sulle decisioni della Corte Suprema, della Commissione sulla performance giudiziaria, e di altre fonti pertinenti. Cfr. <http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/comm/>

partecipante di decidere la durata della sua partecipazione alla mediazione, compreso il diritto di ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento.

Il mediatore deve altresì astenersi dal costringere una delle parti a prendere una decisione o a continuare la partecipazione alla mediazione.

In tema di riservatezza si prevede che il mediatore debba osservarne in ogni momento il principio ed informarne i partecipanti alla mediazione; prima dell'inizio della mediazione deve fornire la spiegazione di che cosa si intenda per riservatezza in generale; se un mediatore parla separatamente con uno o più partecipanti, dopo che tutte le parti hanno accettato di partecipare alla procedura e lo stesso mediatore ha accettato di condurre la mediazione, il mediatore deve come prima cosa discutere coi partecipanti le regole della mediazione in tema di confidenzialità per le comunicazioni separate⁵⁶.

Un mediatore non deve utilizzare le informazioni che acquisisce con la fiducia nel corso di una mediazione al di fuori della procedura o per interessi personali⁵⁷.

Circa l'imparzialità si stabilisce che il mediatore è tenuto a mantenerla in ogni momento verso tutti i partecipanti al processo di mediazione.

Deve fare inoltre sforzi ragionevoli⁵⁸ per mantenersi sempre informato su questioni che ragionevolmente potrebbero sollevare domande circa la sua capacità di condurre la procedura in modo imparziale, ed è obbligato a manifestare tali questioni alle parti.

In particolare le questioni su cui deve mantenersi sempre informato comprendono: (A) il passato, il presente, e gli interessi correnti, le relazioni, e le affiliazioni di carattere personale, professionale, o finanziario, e (B) l'esistenza di eventuali motivi di ritorsione che valgono per il giudice (sezione 170,1 C.p.c.).

Il dovere del mediatore di comunicare queste informazioni è un impegno continuo, dall'avvio del processo di mediazione al suo completamento.

Le informazioni richieste dalla regola 3,855 devono essere comunicate alle parti non appena possibile dopo che il mediatore ne viene a conoscenza e per quanto possibile, tali informazioni devono essere rivelate prima della sessione di mediazione introduttiva⁵⁹.

⁵⁶ Rule 3,854 Reorganized California Rules Of Court.

⁵⁷ Rule 3,854 Reorganized California Rules Of Court.

⁵⁸ Ossia deve verificare se agli occhi di una persona ragionevole le informazioni potrebbero comportare domande sulla sua capacità di condurre una mediazione (*Advisory Committee Comment*).

Se il mediatore divulga le informazioni e queste non destano né domande né preoccupazioni delle parti, può continuare a condurre la procedura a meno che tale prosecuzione non violi ogni altra disposizione delle regole della Corte, qualsiasi legge, o qualsiasi regola del tribunale locale o le linee guida del programma.

A prescindere dal consenso delle parti il mediatore non può continuare la procedura se non è in grado di mantenere l'imparzialità nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura o se la sua condizione metterebbe in pericolo l'integrità del tribunale o del processo di mediazione⁶⁰.

Può accadere che sorga un conflitto tra l'obbligo del mediatore di mantenere la riservatezza e l'obbligo di fare una rivelazione: il mediatore deve stabilire se può effettuare una divulgazione generale della circostanza senza rivelare informazioni riservate, oppure se deve semplicemente rifiutarsi di condurre la mediazione⁶¹.

Fondamentale per i nostri studi è la regola 3,857 in relazione alla qualità della mediazione. Un mediatore deve fare ragionevoli sforzi per far procedere la mediazione in modo tempestivo. Se ha pianificato la mediazione per un determinato periodo di tempo, deve far sì che tale periodo di tempo sia rispettato senza assumere altri impegni.

Un mediatore deve condurre il procedimento di mediazione in modo proceduralmente equo.

Per "Equità procedurale" si intende un processo equilibrato in cui a ciascuna parte è data l'opportunità di partecipare e prendere decisioni senza coercizioni.

Un mediatore non è invece obbligato ad assicurare la correttezza sostanziale di un accordo raggiunto dalle parti.

In aggiunta alla spiegazione dei requisiti inerenti la partecipazione volontaria, la riservatezza, la autodeterminazione, il ruolo professionale del mediatore in generale, il mediatore deve esplicitare la natura della mediazione, le procedure che si utilizzeranno, il ruolo del mediatore, delle parti e degli altri partecipanti nella particolare procedura.

⁵⁹ E in ogni caso, esso devono essere presentate alle parti entro il tempo richiesto dalle norme processuali applicabili o dagli statuti.

⁶⁰ Rule 3,855 Reorganized California Rules Of Court.

⁶¹ *Advisory Committee Comment*.

Circa il ruolo professionale il mediatore deve specificare che nella mediazione non assisterà alcuna delle parti come avvocato o come consulente in qualsivoglia specialità professionale, ma si limiterà a svolgere il ruolo di mediatore imparziale.

Fatti salvi i principi di imparzialità e di auto-determinazione, il mediatore può fornire informazioni o opinioni sulla sua formazione o sulle sue esperienze professionali.

Nel rispetto dei principi di cui sopra, e se è qualificato per farlo, un mediatore può (1) discutere le opzioni di una parte, includendo nella discussione anche i possibili risultati di una procedura arbitrale, (2) offrire un giudizio personale od un parere su una serie di fatti presentati, avendo cura che la parte chiaramente identifichi tale giudizio o parere come personale del mediatore, (3) comunicare l'opinione del mediatore o spiegare ciò che dice la legge o come essa si applica all'oggetto della mediazione, avendo l'accortezza di non suggerire ad alcuna parte come rispettare la legge o che posizione la parte possa prendere alla luce del parere ricevuto⁶².

Ci si chiede in California se la valutazione del mediatore sulle domande processuali, sulle difese, o sugli esiti possibili della controversia costituisca parere legale o pratica della legge.

Problemi analoghi possono presentarsi con riferimento alla contabilità, all'architettura, all'edilizia, al counseling, alla medicina, alla pratica immobiliare, o altre professioni per cui è necessaria una licenza che divengano rilevanti per una mediazione.

Il mediatore dovrebbe essere cauto nel fornire informazioni o opinioni relative a qualsiasi settore per il quale è richiesta una licenza professionale, perché potrebbe non avere la licenza, od averla ma comunque violare i regolamenti della professione per cui il mediatore è autorizzato ad esercitare.

Il mediatore è tenuto inoltre ad esercitare una cautela particolare quando si discute di legge con parti non rappresentate da difensore e dovrà sempre informare le parti che hanno la facoltà di richiedere una consulenza indipendente ad un avvocato.

Un mediatore può raccomandare l'uso di altri servizi in relazione a una mediazione e può raccomandare particolare fornitori di questi servizi. Tuttavia, un mediatore deve

⁶² *Advisory Committee comment.*

comunicare eventuali interessi personali o finanziari connessi con i servizi di specifici individui o le organizzazioni che raccomanda.

A noi questo principio può apparire strano, ma abbiamo visto che ad esempio nel programma CMADRESS la sessione informativa dura solo tre ore ed è quindi naturale che per il prosieguo della mediazione si possa chiedere raccomandazioni al mediatore.

Principio interessante è quello per cui un mediatore può portare a conoscenza delle parti gli interessi di altri che non partecipano alla mediazione, ma che possono essere influenzati da accordi raggiunti a seguito della mediazione.

Altra regola che dovremmo avere di mira è quella per cui il mediatore deve combinare con cautela la mediazione ed altri strumenti ADR e può farlo solo con il consenso informato delle parti e in maniera coerente con qualunque legge o ordinanza del tribunale.

Il mediatore è obbligato ad informare le parti in generale della natura dei diversi processi e delle conseguenze che possono derivare dalla rivelazione di informazioni acquisite durante qualsiasi processo in altro processo, e deve dare alle parti la possibilità di scegliere un altro terzo neutrale per il successivo processo.

Se vi è il consenso delle parti ad una combinazione di processi ADR, il mediatore deve chiaramente informare i partecipanti quando si verifica il passaggio da un processo all'altro.

Coerentemente con il fatto che il mediatore non può essere avvocato e consulente di alcuna parte, un mediatore può presentare opzioni di possibile risoluzione e termini per la discussione.

Può anche assistere le parti nella preparazione di un accordo transattivo scritto, a condizione che in tal modo il mediatore rispetti quello che è l'accordo voluto dalle parti.

Il mediatore può sospendere o porre fine alla mediazione o cessare di essere mediatore, quando possa ragionevolmente ritenere che lo richiedano le circostanze e quando sospetti che: (1) la mediazione è stata utilizzata per portare avanti comportamenti illeciti; (2) un partecipante non è in grado di partecipare in modo significativo ai negoziati, o (3) la prosecuzione della procedura potrebbe arrecare un danno significativo a qualche partecipante o ad un terzo.

Quando il mediatore stabilisce che è necessario sospendere o interrompere una mediazione o ritirarsi dalla procedura, deve provvedere senza violare l'obbligo della riservatezza e in maniera da recare il minor danno possibile per i partecipanti⁶³.

Circa la competenza del mediatore californiano possiamo dire che non è necessario come pre-requisito una particolare specializzazione post laurea od esperienza professionale⁶⁴.

Le capacità di base della mediazione comprendono il saper comunicare chiaramente, il saper ascoltare in modo efficace, il saper facilitare la comunicazione tra tutti i partecipanti, il promuovere l'esplorazione delle opzioni di accordo reciprocamente accettabili e il saper condurre se stessi in modo neutrale⁶⁵.

La *rule 3,856* stabilisce che il mediatore deve possedere esperienza, formazione, istruzione e gli altri requisiti stabiliti dal giudice per la nomina e la conservazione nel ruolo.

Un mediatore ha inoltre l'obbligo di continuare a rappresentare fedelmente il suo background alla Corte e ai partecipanti. Su richiesta di una delle parti, il mediatore deve fornire informazioni veritiere in merito la propria esperienza, alla formazione e all'istruzione.

Inoltre ha l'obbligo di continuare a valutare se il suo livello di abilità di base, conoscenze e capacità sia sufficiente a condurre la mediazione in modo efficace.

In particolare deve rifiutare di condurre la procedura o di continuare la mediazione se si rende conto che non possiede il livello di abilità di base, di conoscenza, o di capacità necessarie a condurre la procedura in modo efficace.

Il mediatore deve considerare e valutare tutta una serie di questioni, per determinare se abbia o meno in quella particolare mediazione il livello di abilità di base, di conoscenza, o di capacità necessarie.

⁶³ Rule 3,857 Reorganized California Rules Of Court.

⁶⁴ *"No particular advanced academic degree or technical or professional experience is a prerequisite for competence as a mediator"*. Advisory Committee Comment.

Nel Northern district of California i mediatori devono aver fatto i procuratori per almeno 7 anni e devono essere informati circa contenzioso civile in un tribunale federale. Devono possedere spiccate abilità di base. I mediatori che non sono avvocati possono anche essere selezionati per far parte del pannello della Corte dei mediatori se hanno le credenziali professionali adeguate in un'altra disciplina e sono informati sullo svolgimento delle controversie civili in Tribunale federale. Un mediatore che non sia avvocato può essere nominato in un caso solo con il consenso delle parti (Local Rule 2. 5, 3).

⁶⁵ *"Core mediation skills include communicating clearly, listening effectively, facilitating communication among all participants, promoting exploration of mutually acceptable settlement options, and conducting oneself in a neutral manner"*. Advisory Committee Comment.

Le questioni da porsi sono le seguenti: 1) se le parti siano state coinvolte od abbiano promosso il processo di scelta del mediatore, 2) se abbiano avuto accesso alle informazioni relative al background del mediatore o al suo livello di abilità di base, di conoscenze e di capacità, 3) se abbiano una specifica aspettativa o percezione inerente al livello di abilità di base, di conoscenze e di capacità del mediatore, 4) se abbiano espresso una preferenza per lo stile della mediazione, 5) se abbiano espresso il desiderio di discutere della normativa o di altre informazioni tecniche, per ascoltare una valutazione personale o una opinione su una serie di fatti che vengono presentati o per essere messe a conoscenza di interessi di persone che non sono parte della procedura⁶⁶.

Nel distretto settentrionale della California che ricomprende ad esempio la contea di San Francisco o di Santa Clara si utilizzano l'arbitrato non vincolante, la mediazione, la valutazione neutrale e su ordine del giudice la *settlement conference* parimenti guidata da un giudice.

Gli strumenti privati di ADR che non rientrano nel programma della Corte⁶⁷ devono essere autorizzati dal giudice e non godono della disciplina approntata col programma.

La Corte di Santa Clara avverte sul proprio sito internet che l'esperimento della mediazione può essere per ciascuno un'esperienza molto più importante del giudizio⁶⁸.

Ciò non significa che la Corte ordini alle parti un percorso ADR, ma di sicuro lo incentiva, visto che sino alla decisione si può sempre praticarlo e che il giudice può concedere tutto il tempo necessario.

Nella contea di Santa Clara il cittadino californiano che desidera risolvere in ADR una controversia contatta direttamente la controparte od il suo legale.

Oppure può recarsi, se lo desidera, dall'avvocato per scegliere lo strumento più idoneo; l'avvocato contatterà direttamente l'altra parte (od il suo legale) e chiederà se questa voglia o meno utilizzare un metodo ADR e quale metodo.

⁶⁶ Advisory Committee Comment. Sulla confidenzialità della procedura di reclamo avverso i comportamenti del mediatore si veda la rule 3,867 Reorganized California Rules Of Court.

⁶⁷ Multi-Option program.

⁶⁸ "In mediation, experience with the mediation process can be much more important than experience with the law that the case involves". V. http://www.sccourt.org/self_help/civil/adr/adr_med_and_eval.shtml; la Corte avverte altresì che quando si opta invece per la valutazione neutrale si deve scegliere la persona che sia più ferrata nella legge del diritto controverso.

Se le parti sono d'accordo nell'affrontare un metodo risoluzione alternativa contattano l'amministratore dell'ADR tramite il sito della Corte⁶⁹ o l'organismo che dispensa l'ADR scelto: ogni organismo ha una lista di mediatori, valutatori neutrali od arbitri che può essere consultata.

Il mediatore o valutatore ricevono nel proprio ufficio, o in altro luogo concordato dalle parti.

La documentazione da depositare viene decisa dal mediatore: spesso richiedono alle parti informazioni generali sulla controversia, ma anche una proposta di risoluzione della controversia⁷⁰.

L'onorario del mediatore va dai 100 ai 550 dollari orari⁷¹. La mediazione dura dalle tre alle cinque ore.

Se le parti sono d'accordo sull'utilizzo di un metodo alternativo sottoscrivono dunque un'intesa su apposito modulo⁷² che viene depositato presso la Corte a cura dell'attore o del ricorrente.

In questo modulo si avverte la Corte che le parti hanno scelto un metodo ADR, si indica il tipo di ADR che si intende utilizzare, e si evidenzia chi dovrà essere il mediatore o valutatore e quando si svolgerà l'incontro. Si comunica altresì alla Corte la data in cui si terrà la sessione di ADR.

Se la domanda di ADR alla Corte viene fatta anteriormente alla prima udienza già fissata, ed è necessario un tempo maggiore per la conclusione del processo di ADR, si otterrà una nuova fissazione⁷³.

Se le parti non sono d'accordo su che metodo ADR utilizzare è lo stesso Giudice che in sede di prima udienza (*Case management conference*) deciderà sul da farsi.

⁶⁹ L'amministratore ADR possiede una lista di mediatori, di valutatori neutri e di arbitri e privati che può aiutare e che si può raggiungere tramite la rete. L'amministrazione di ADR può essere raggiunto anche telefonicamente: l'orario è dalle 8 alle 17.

⁷⁰ Ciò era già per inciso già un portato del nostro ordinamento ottocentesco laddove il conciliatore non era obbligato a prestarsi ciecamente a qualsiasi richiesta: "può quindi sentire il bisogno di illuminarsi preventivamente sull'indole della controversia, di esaminare i documenti, e gli atti di giudizio per avventura già vertente sulla medesima...". V. L. SCAMUZZI, *Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori e dei loro Cancellieri ed Usceri*, III ed., E. Rechiedei & C., 1893, p. 175.

⁷¹ Ma vi è anche la possibilità di partecipare ad una mediazione gratuita: è la Corte a decidere se si hanno i requisiti e vi sono anche dei programmi.

⁷² ADR stipulation and order form. Cfr. http://www.scsccourt.org/forms_and_filing/forms/cv-5008.pdf

⁷³ Si deve depositare un *form* che si chiama *Stipulation and Proposed Order*.

In caso di accordo bisogna depositare la comunicazione presso la Corte e si può chiedere anche di non estinguere il procedimento fino a che gli obblighi derivanti dall'accordo non siano adempiuti.

La Corte Suprema della California ci spiega che nella procedura di arbitrato, una persona neutrale chiamato "arbitro" ascolta gli argomenti e valuta le prove addotte da ogni parte e poi decide l'esito della controversia⁷⁴.

L'arbitrato è una procedura meno formale rispetto al processo, e le regole per la formazione della prova sono spesso meno strette.

L'arbitrato in California può essere obbligatorio o non obbligatorio⁷⁵, vincolante o non vincolante⁷⁶.

In sede di arbitrato vincolante le parti rinunciano a un processo e decidono di accettare la decisione arbitrale come definitiva. Generalmente, non esiste un diritto di appellare la decisione vincolante di un arbitro.

Se l'arbitrato non è vincolante le parti sono invece libere di impugnare la decisione dell'arbitro che non accettano.

L'arbitrato è lo strumento ADR più indicato quando le parti vogliono che un'altra persona decida per loro l'esito della loro controversia e ciò volendo però desiderino evitare le formalità, i tempi e le spese di un processo.

Può anche essere opportuno per le questioni complesse in cui le parti vogliono che il loro giudice abbia una particolare formazione od esperienza nella materia oggetto della controversia.

L'arbitrato non costituisce scelta idonea se le parti vogliono mantenere il controllo sulle modalità di risoluzione della controversia ed in particolare quando lo strumento sia vincolante.

In sede di arbitrato vincolante le parti in genere, come accennato, non possono appellare il lodo arbitrale, anche se esso non sia supportato da prove o dalla legge.

⁷⁴ <http://www.courts.ca.gov/3074.htm>

⁷⁵ Non vincolante è ad esempio nel Distretto Settentrionale della California.

⁷⁶ Il Codice di procedura civile della California prevede che per le questioni di valore inferiore ai 50.000 \$ l'arbitrato sia obbligatorio.

Anche nell'arbitrato non vincolante però se una parte fa appello e non ottiene un risultato più favorevole rispetto a quello portato dal lodo può essere soggetta a sanzioni.

Detto questo assolutamente in generale aggiungiamo che il Codice di procedura civile californiano si occupa dell'arbitrato alla Sezione 1441⁷⁷.

Scopriamo dai principi preliminari che le udienze arbitrali quando è possibile si tengono fuori dall'orario giudiziale e che gli avvocati dello Stato che fungono da arbitri oltre ad avere esperienza con i casi oggetto della controversia dovrebbero prestare la loro opera gratuitamente⁷⁸.

In ogni Corte superiore che abbia almeno 10 giudici, o in ogni contea che abbia almeno 18 giudici e non abbia una corte municipale, il giudice decide di mandare in arbitrato ogni causa che non sia di valore inferiore ai 25.000 \$ (*limited civil action*⁷⁹), ma che sia di valore inferiore a 50.000 \$ per ogni attore⁸⁰; se invece i giudici della corte sono meno di 10 o meno di 18 sono i giudici della Contea, la Corte può stabilire con regola locale, quando ciò sia nel migliore interesse della giustizia, che tutte le cause civili ove valore per ogni attore sia inferiore a 50.000 \$ siano inviate dal Presidente o dal Giudice in arbitrato⁸¹. In entrambi i casi la decisione degli arbitri è inappellabile.

Ogni Tribunale municipale, o Corte superiore in una Contea in cui non ci sia alcun giudice comunale, può prevedere con regola locale, quando ciò sia nel migliore interesse della giustizia, che le cause superiori a 25.000 € siano sottoposte ad arbitrato, dal Presidente o il Giudice⁸².

In ogni Corte che abbia adottato l'arbitrato giudiziario ai sensi della Sezione 1441, 11, tutte le *limited civil cases* che involgono un risarcimento danni da sinistro automobilistico nei confronti di un solo convenuto, ad eccezione di quelli di competenza delle *small court claims*, dovranno andare in arbitrato entro 120 giorni dal deposito, salvo proroga del

⁷⁷ La sezione è stata prevista sin dal 1979.

⁷⁸ Sezione 1441 B 2) 3) CALIFORNIA CODE OF CIVIL PROCEDURE.

⁷⁹ V. art. 85-89 CALIFORNIA CODE OF CIVIL PROCEDURE.

⁸⁰ Sezione 1441,11 A. In tal caso, in assenza di patto contrario, alcuna *discovery* diversa da quella consentita dalla Sezione 2034 è permessa dopo l'emanazione del lodo arbitrale, salvo autorizzazione del tribunale in presenza di giusta causa.

⁸¹ Sezione 1441,11 B. Il consiglio giudiziario può prevedere eccezioni nei casi in cui le azioni civili non si prestano ad essere trattate in arbitrato. Sezione 1441,15.

⁸² La presente sezione non si applica alle azioni di competenza della *small claims court* (sino a 7.500 \$), o per qualsiasi azione ai sensi della Sezione 1781 del Codice Civile (reclami dei consumatori) o della Sezione 1161 dello stesso Codice (particolari controversie in materia di locazione immobiliare).

termine per giusta causa, della comparsa di risposta davanti ad un arbitro scelto dalla Corte⁸³.

In ogni Corte Superiore in cui l'arbitrato si tiene in base alle sezioni 1441,11 A e B, se sussiste una clausola contrattuale, l'arbitrato può essere tenuto a prescindere dal valore della controversia⁸⁴.

Nelle altre Corti superiori o Tribunali il Consiglio giudiziario deve adottare delle regole per un sistema di arbitrato uniforme:

- 1) in presenza di clausola arbitrale contrattata tra le parti,
- 2) quando l'attore scelga l'arbitrato depositando apposito memorandum 90 giorni prima dell'udienza (o nel termine prescritto dal giudice) ed in esso dichiarare che il valore del lodo non potrà superare i 50.000 \$⁸⁵.

La sezione 1441 non si applica al caso in cui una parte chieda che il giudice si pronunci secondo equità⁸⁶.

La determinazione del valore della controversia viene fatta dal Giudice in apposita udienza a cui sono presenti le parti con i difensori⁸⁷. Il giudice valuta anche la portata della richiesta di giusto indennizzo. In nessuna caso si procederà ad arbitrato se entrambi le parti assumono concordemente per iscritto che il valore è superiore a 50.000 \$.

Nel caso venga deciso per l'arbitrato si deve provvedere a nominare l'arbitro entro 30 giorni⁸⁸.

Gli arbitri sono giudici in pensione, commissionari del Tribunale⁸⁹ oppure Avvocati dello Stato⁹⁰. Anche un Giudice può fungere da arbitro, ma senza indennizzo.

Le parti possono tuttavia indicare come arbitro anche un non legale⁹¹.

⁸³ Che non sia incompatibile ai sensi delle sezioni 170,1 e 170,6 del C.p.c.

⁸⁴ Sezione 1441,12 A.

⁸⁵ Sezione 1441,12 B e C.

⁸⁶ *"This chapter shall not apply to any civil action which includes a prayer for equitable relief, except that if the prayer for equitable relief is frivolous or insubstantial, this chapter shall be applicable"*. Sezione 1441,13

⁸⁷ La determinazione che tiene conto dell'ammontare dei soli danni è fatta ai soli fini dello strumento alternativo; l'arbitro potrà farne un'altra e nel giudizio verrà fatta ex novo (Sezione 1441, 16).

⁸⁸ Sezione 1441, 16.

⁸⁹ Sono avvocati o giudici in pensione o giuristi di esperienza a cui il Tribunale commette questioni complesse. Possono fare anche da testimoni negli atti di ultima volontà ed occuparsi ad esempio dei minori o delle modifiche alimentari nell'ambito della famiglia.

⁹⁰ Gli arbitri rientrano in liste specializzate le cui regole sono fissate dal Consiglio dei governatori dei foro dello Stato (Sezione 1441,18 C).

⁹¹ Sezione 1441, 18 A.

Gli arbitri possono essere ricusati ed in alcuni casi⁹² sono tenuti ad astenersi, se vi sia richiesta delle parti prima della conclusione del procedimento

Il diritto alla retribuzione dell'arbitro scatta nel momento del deposito del lodo o dell'accordo delle parti; il compenso può essere, salvo deroga, di 150 \$ per caso o al giorno, salvo che la Contea o la Città contea preveda importi superiori.

Il lodo arbitrale sarà definito a meno che non ci sia una richiesta di processo entro 30 giorni.

Il processo può essere tenuto dal giudice o da una giuria ed è in fatto ed in diritto; la calendarizzazione deve essere fatta come se l'arbitrato non ci fosse mai stato⁹³.

Tuttavia se la sentenza stabilirà un ammontare di risarcimento inferiore a quello riconosciuto dal lodo o concederà uno sgravio inferiore alla parte che ha richiesto il nuovo giudizio, il giudice ordinerà che tale ultima parte sopporti determinate spese e costi non ripetibili, a meno che su impulso della parte il Tribunale non dichiari per iscritto che ciò determinerebbe un disagio economico che non è nell'interesse della giustizia⁹⁴.

Ipotesi quest'ultima che dovrebbe essere presa in seria considerazione per una riforma dell'art. 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Le spese e i costi non ripetibili che vengono sopportati dalla parte che ha scelto il giudizio infruttuoso sono i seguenti: il compenso arbitrale sostenuto dalla Contea⁹⁵, le spese legali sostenute dalle altre parti e dalla parte che ha promosso il giudizio, i costi effettivamente sostenuti o che ragionevolmente saranno da sostenere per assoldare testimoni esperti, il compenso arbitrale corrisposto dall'altra parte quando l'arbitrato non sia intentato ai sensi della regola 1141 (ossia il 50% dei costi arbitrali, ad eccezione del caso in cui sia intervenuta la Contea per riequilibrare il rapporto tra le parti).

Si specifica però che tali costi e spese, oltre al compenso dell'arbitro, saranno quelli da sostenersi a partire dal momento della elezione del nuovo processo.

⁹² Sezione 170,1 del Codice di rito.

⁹³ Sezione 1441,20 B.

⁹⁴ Sezione 1141, 21.

⁹⁵ Eccettuato il caso in cui, scelti dalle parti gli arbitri non ai sensi della sezione 1441, vi sia stato un grave disequilibrio economico e allora la Contea stessa abbia sostenuto i costi della parte in difficoltà.

Se la parte che elegge il processo ha proceduto *in forma pauperis*⁹⁶ e non è riuscita a ottenere una sentenza più favorevole, i costi e le spese legali e per i testimoni sono imposte solo nel caso possano compensarsi con gli eventuali risarcimenti concessi a favore di quella parte.

Se la parte che elegge il processo *de novo* ha proceduto *in forma pauperis* e non è riuscito a ottenere una sentenza più favorevole, i costi dell'arbitrato sono imposti esclusivamente nella misura in cui resta un importo sufficiente a seguito della deduzione in compensazione effettuata per i testimoni e le spese legali⁹⁷.

Il lodo in forma scritta viene sottoscritto dall'arbitro e depositato in Tribunale.

Se non c'è richiesta di un nuovo processo e di annullamento del lodo quest'ultimo entrerà nel fascicolo del giudizio ed avrà la stessa forza di una sentenza con la differenza che non sarà impugnabile se non per effettuare una correzione di un errore materiale⁹⁸ o davvero in casi limite: se il lodo è frutto di corruzione, frode od altri indebiti mezzi, se i diritti di una parte sono compromessi in modo sostanziale per colpa di un arbitro, se gli arbitri hanno pronunciato fuori dalla competenza ed il lodo non può essere corretto se non alterando la sostanza della decisione, se c'era un motivo di riconsiliazione e l'arbitro ne era a conoscenza ed ha omesso di comunicarlo alle parti nel tempo prescritto, se l'arbitro ha pronunciato il lodo quando doveva astenersi dalla procedura⁹⁹.

Le spese dell'arbitrato sono di regola a carico della Contea, salvo il caso visto in cui sia stato concesso un ammontare di risarcimento inferiore a quello riconosciuto dal lodo o concesso uno sgravio inferiore alla parte che ha richiesto il nuovo giudizio¹⁰⁰.

Il compenso degli arbitri in qualsiasi procedimento che altrimenti non sarebbero soggetti alle disposizioni già viste, ma in cui l'arbitrato si svolge ai sensi delle stesse per clausola intervenuta tra le parti, deve essere corrisposto in parti uguali dalle parti¹⁰¹.

⁹⁶ Ai sensi del gratuito patrocinio che però in California non copre le spese legali e quelle necessarie ad acquisire le prove nel processo.

⁹⁷ Sezione 1141, 21.

⁹⁸ Sezione 473.

⁹⁹ Sezione 1286, 2. La regola non si applica agli arbitrati che in sede lavoristica hanno ad oggetto i contratti collettivi.

¹⁰⁰ Sezione 1441, 28 A.

¹⁰¹ Sezione 1441, 28 B.

Vi è poi da considerare – ci suggerisce sempre la Corte Suprema¹⁰² – la valutazione neutrale (*neutral evaluation*)¹⁰³ che non ha come obbiettivo centrale quello del raggiungimento di un accordo, ma che può tradursi comunque in una soluzione della controversia.

Ciascuna delle parti ha la possibilità di presentare il suo caso a un terzo neutrale chiamato "valutatore" (*evaluator*).

La valutazione neutrale può essere più appropriata nei casi in cui ci sono problemi tecnici che richiedono una speciale competenza nella risoluzione o quando l'unica questione da discutere è l'ammontare del risarcimento dei danni.

La valutazione neutrale non è invece appropriata quando ci siano significative barriere fisiche o emotive che ostacolano la risoluzione della controversia.

Il valutatore ha come compito quello di migliorare la comunicazione diretta tra le parti in merito alle loro richieste ed agli elementi di prova, entra nel merito della causa e fornisce un "*reality check*" per le parti e per i loro avvocati (ossia le prospettive che si possono realmente vantare e quelle che vanno abbandonate)¹⁰⁴, identifica e chiarisce le questioni centrali della controversia, assiste le parti nella pianificazione formale di una *discovery* o nello scambio informale di informazioni, e facilita la discussione tesa all'accordo, se ciò viene richiesto dalle parti¹⁰⁵.

Il valutatore è spesso un esperto nella materia oggetto della controversia¹⁰⁶.

Anche se il parere del valutatore non è vincolante, le parti in genere lo utilizzano come base per cercare di negoziare una soluzione della controversia.

Vediamo ancora brevemente come si svolge la valutazione neutrale nel Distretto Settentrionale della California.

¹⁰² Ha sede in San Francisco.

¹⁰³ Riportiamo qui di seguito un accenno alla specifica disciplina della *local rule 5* del Distretto Settentrionale della California (che ricomprende 15 contee tra cui San Francisco e Santa Clara) in <http://www.cand.uscourts.gov/ene>.

¹⁰⁴ Il valutatore fornisce, in altre parole, un parere sui punti di forza e di debolezza in tema di argomenti e prove addotte da ciascuna parte e su come la controversia può essere risolta.

¹⁰⁵ Cfr. Local rule 5-1 dicembre 2009.

¹⁰⁶ Nel Distretto Nord è un avvocato che ha almeno 15 anni di esperienza da procuratore nei tribunali federali, è un esperto della materia che gli viene sottoposta e possiede le abilità di base per facilitare la comunicazione tra le parti e per condurle ad un accordo (Local rule 2-5 B 2 dicembre 2009).

Il valutatore neutrale incontra le parti in una riunione informale¹⁰⁷. Ogni parte tramite il proprio legale o attraverso testimoni presenta le sue prove, senza che si tenga conto delle regole che normano la formazione delle prove e senza che si faccia luogo all'interrogatorio diretto o al controinterrogatorio dei testimoni.

Il valutatore identifica le aree di accordo, chiarisce e mette a fuoco le questioni e incoraggia le parti a formulare un accordo per semplificare o ridurre il contenzioso e risparmiare sui costi (*stipulation*).

Di seguito il valutatore predispone una relazione che include una stima, ove possibile, del grado di responsabilità e dell'ammontare del danno, una valutazione dei punti di forza e di debolezza del caso di ciascuna parte, e i ragionamenti che supportano queste valutazioni.

A questo punto il valutatore chiede alle parti se vogliono ascoltare la sua relazione¹⁰⁸.

Se una parte lo richiede il valutatore la deve esporre, ma le parti possono anche chiedere di posporre la lettura e di effettuare delle sessioni private in facilitazione, ovvero di procedere ad una *discovery* mirata.

Se la negoziazione non ha effetto il valutatore può aiutare le parti nella *discovery* in modo che ne possa sortire una transazione ovvero può aiutare a preparare le posizioni di ognuno per il processo e/o a valutare realisticamente le spese processuali e/o a stabilire se esiste una qualche forma di approfondimento (*follow up*)¹⁰⁹ della sessione che contribuisca a sviluppare il caso o a trovare un accordo.

¹⁰⁷ Cfr. Local rule 5-11 dicembre 2009

¹⁰⁸ L'esposizione deve essere orale. Successivamente il valutatore consegnerà alle parti un testo scritto.

¹⁰⁹ Può trattarsi di una conferenza telefonica con i legali, nello scambio di corrispondenza o di memorie con i legali. Il valutatore può anche richiedere che si risponda ad una eventuale offerta di chiusura della controversia (Local rule 5-13 dicembre 2009).

Tutte le controversie possono potenzialmente essere oggetto di *neutral evaluation* a patto che presso la Corte esistono delle professionalità adeguate ad affrontarle¹¹⁰.

La *neutral evaluation* può tenersi su ordine od iniziativa del giudice ovvero su richiesta delle parti¹¹¹.

C'è un'unità di ADR che provvede a nominare il valutatore dal *panel* giudiziario e comunica la nomina alle parti perché possano esercitare il diritto di riconsuazione.

Il valutatore deve al più presto contattare le parti telefonicamente per stabilire in accordo con essi la data ed il luogo della valutazione: gli avvocati delle parti devono dare piena collaborazione al valutatore e rispettare la programmazione.

La seduta deve tenersi entro 90 giorni dal deferimento in ENE: il termine può essere prorogato a seguito di richiesta depositata presso la Corte almeno 14 giorni prima della seduta¹¹²; la richiesta deve indicare le ragioni della proroga e se le altre parti sono o meno d'accordo.

Fino a che il valutatore non ha redatto la sua relazione non ci sarà alcun incontro privato con ciascuna parte, all'infuori di quello sulla programmazione della seduta¹¹³.

Sette giorni prima della seduta le parti devono presentare direttamente al valutatore e scambiarsi tra di loro un "*ENE Statement*" a cui si allegano i documenti, in cui si identificano le parti, gli eventuali rappresentanti, le terze parti coinvolte (ad esempio l'assicurazione), la natura della procedura; questo documento è assolutamente confidenziale e non può venire a conoscenza del giudice¹¹⁴.

Alla seduta si deve di regola partecipare di persona¹¹⁵; le persone non fisiche possono essere rappresentate da soggetti che conoscano l'oggetto di causa¹¹⁶.

¹¹⁰ Local rule 5-2 dicembre 2009.

¹¹¹ Local rule 5-2 dicembre 2009.

¹¹² Local rule 5-4 e 5-5 dicembre 2009.

¹¹³ Local rule 5-6 dicembre 2009.

¹¹⁴ Local rule 5-8 dicembre 2009.

¹¹⁵ Anche i rappresentanti dell'assicurazione se il loro assenso è necessario per un accordo. Si può chiedere di essere esentati se la partecipazione determina un onere straordinario ed ingiustificabile. Va fatta però la richiesta al magistrato dell'ADR (e va comunicata alle altre parti ed al valutatore) almeno quattordici giorni prima della seduta e l'altra parte si può opporre. Una parte può anche sostenere che l'altra parte designata per la ENE non sia adeguatamente rappresentata e tale ultima parte ha diritto di replica: le modalità di comunicazione della richiesta sono le stesse. Chi venga esentato dal partecipare deve essere disponibile a partecipare per telefono sino a che il valutatore non lo dispensa.

¹¹⁶ Local rule 5-10 dicembre 2009.

Le parti devono essere accompagnate dagli avvocati che li assisteranno nel processo¹¹⁷.

Il principio di riservatezza domina la sessione di ENE¹¹⁸.

Il valutatore svolge gratuitamente la procedura per le prime 4 ore; il compenso è dovuto per le successive 4 ore della valutazione e si paga di regola allo scadere (se il caso richiede più di 8 ore si possono stabilire regole differenti)¹¹⁹.

Un altro strumento utilizzato è quello delle *Settlement Conferences*: sono convegni di composizione che possono essere obbligatori o volontari.

I convegni di composizione sono appropriati in ogni caso in cui il raggiungimento di un accordo costituisce un'opzione delle parti.

In *Settlement Conference*, le parti e i loro avvocati incontrano un giudice o una persona neutrale detto "ufficiale di componimento" (*settlement officer*) per discutere la possibile risoluzione della controversia.

Il giudice o l'ufficiale non decidono il caso, ma aiutano le parti a valutare i punti di forza e di debolezza del caso e a negoziare un accordo¹²⁰.

Il giudice o l'ufficiale possono utilizzare la mediazione facilitativa, ma non è un obbligo; in ogni caso le regole sulla riservatezza della mediazione non si applicano ai convegni di composizione obbligatori¹²¹.

Nel Distretto della California quando una questione rientra nel programma ADR *Multi-Option*, ossia è stato assegnata ad ADR obbligatorio, l'iniziativa per un convegno di composizione può essere presa dalle parti in ogni momento; le parti possono anche scegliere il giudice che terrà il convegno e la loro richiesta viene assecondata se compatibile con l'organico a disposizione del tribunale.

È lo stesso giudice designato per il convegno che notifica alle parti la data dello stesso ed i requisiti necessari e può anche ordinarne la composizione personale¹²².

Qualora non indichi particolari requisiti la legge precisa che una parte diversa dalla persona fisica può partecipare se possiede i poteri per concludere accordi ed è a piena

¹¹⁷ Local rule 5-10 2 (b) dicembre 2009.

¹¹⁸ Local rule 2-12 dicembre 2009.

¹¹⁹ Local rule 5-3 dicembre 2009. Il valutatore neutrale deve comunicare alla unità di ADR quanto ha ricevuto dalle parti (Local rule 5.3 dicembre 2009).

¹²⁰ V. per una definizione ad esempio la Local rule 7-1 del Distretto settentrionale della California.

¹²¹ V. Advisory Committee comment Rule 3.1380 2011 California Rules of Court.

¹²² Local rule 7- 4 del Distretto settentrionale della California.

conoscenza dei fatti di causa (non può essere un avvocato esterno); gli assicuratori, salvo dispensa del giudice devono partecipare personalmente.

Il principio di riservatezza implica che il giudice del convegno non possa di norma rivelare alcunché al giudice assegnato per il *trial*.

Hanno contenuto riservato le informazioni eventualmente scritte durante il convegno, tutto ciò che accade e che viene detto durante il convegno, ogni posizione sostenuta dalle parti, ogni punto di vista sul merito della questione in qualche modo collegato col convegno.

Le informazioni riservate non possono essere rivelate ad alcuno che non sia coinvolto nel convegno, nemmeno al giudice designato per il *trial*; le informazioni riservate non possono utilizzate in qualsiasi processo radicato o da radicarsi presso il tribunale del Distretto.

La riservatezza non impedisce che siano rivelate le informazioni che le parti decidono contrattualmente di rivelare; parimenti la riservatezza non copre quelle informazioni che siano richieste alle parti da soggetti autorizzati dal tribunale per monitorare o valutare il giudice dell'ADR o quelle informazioni che sono necessarie a preservare la capacità della Corte di far rispettare i propri ordini o di disciplinare le conseguenze della contumacia¹²³.

I convegni di composizione obbligatoria sono spesso tenuti vicino alla data dell'udienza del processo.

Le regole del convegno di composizione obbligatoria¹²⁴ prevedono inoltre che esso può dipendere dall'iniziativa delle parti o dell'autorità giurisdizionale¹²⁵.

Sino a cinque giorni prima della data fissata per il convegno le parti devono obbligatoriamente consegnare alla Corte una dichiarazione contenente una proposta di composizione da parte sia dell'attore che del convenuto, la ripartizione analitica dei danni economici e non economici invocati dall'attore, l'impegno per ogni parte a individuare e discutere in modo dettagliato in fatto e in diritto tutte le questioni di responsabilità e risarcimento danni coinvolte nel caso.

¹²³ Local rule 7-5 del Distretto settentrionale della California.

¹²⁴ Rule 3.1380 2011 California Rules of Court. V.
http://www.courtinfo.ca.gov/rules/index.cfm?title=three&linkid=rule3_1380

¹²⁵ V. anche la regola 7. 2 del Distretto settentrionale della California, che prevede una triplice modalità in ogni caso.

Il giudice non può nominare come ufficiale di composizione colui che è mediatore nella stessa questione.

Le parti, i loro avvocati e le persone che hanno influenza sulla risoluzione della questione devono partecipare di persona, a meno che non siano esentate dal giudice per giusta causa.